

1500584-10.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas:

Visto em ponto de tráfico, sozinho e parado, o réu colocou algo na boca quando viu a viatura policial. Foi abordado. Porções de maconha foram encontradas em sua boca. E ainda portava dinheiro. Do outro lado da rua, após buscas, os agentes encontraram outras porções do outro lado da rua identicamente embaladas às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500584-10.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

02097436/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2097436/2021 - 2º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO LUIS DE PAIVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Aos 01 dias do mês de fevereiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) FABIO LUIS DE PAIVA e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Paulo Franco Júnior e Joel Vasconcelos de Lima.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Paulo e Joel) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

“MM.Juíza, FÁBIO LUIS DE PAIVA está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,

Feito processado com regularidade.

Procede a ação penal.

DOS FATOS, COM INDICAÇÃO DAS PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de abril de 2021, por volta de 22h05min, na Rua José Alfredo de Castro Neves, n.º 13, Bairro Cecap, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, FÁBIO LUIS DE PAIVA, qualificado e indiciado às fls. 04 e 20/23, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 07 (sete) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., “maconha”, com peso líquido de 8,6g (oito gramas e seis decigramas), bem como guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 18 (dezoito) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., “maconha”, com peso líquido de 31g (trinta e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, FÁBIO estava realizando a mercancia ilícita em via pública. Para dificultar a ação repressiva, trazia poucas porções nas mãos para a venda e escondia outras em um arbusto próximo. Ocorre que, ao notar a aproximação de uma viatura policial, escondeu algumas porções de droga na boca e tentou sair furtivamente. Mas foi abordado pelos agentes que visualizaram seu comportamento evasivo.

Em busca pessoal, os guardas encontraram em seu bolso a quantia de R\$25,00 (vinte e cinco reais) e sete porções de maconha em sua boca. Num arbusto do outro lado da via, localizaram outras 18 (dezoito) porções idênticas àqueles que o denunciado trazia consigo (foto fls. 14). Na delegacia, FÁBIO ficou silente (fls. 04/05). O exame pericial constatou a presença de tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (laudo fls. 17/19).

Considerando as circunstâncias da prisão, notadamente a condição pessoal do agente – prisão em flagrante anterior por idêntica conduta (fls. 33, autos 1501236-61.2020.8.26.0599), a visualização do comportamento furtivo pelos agentes (fls. 02/03), a quantidade e forma de fracionamento das drogas (fls. 14), bem como a apreensão de dinheiro em espécie (R\$ 25,00), é certo que o denunciado trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Joel Vasconcelos de Lima – Guarda Municipal – narrou que estava em patrulhamento quando viu o réu sozinho e parado na via. Ao avistar a viatura, tal indivíduo colocou algo suspeito na boca e tentou deixar o local, sendo abordado. Na boca do réu, encontrou sete porções de maconha. Encontrou dinheiro com ele também. Ele disse que estava traficando. Do outro lado da rua, encontrou mais dezoito porções de maconha idênticas às que estavam com ele. Não se lembra o que ele falou sobre essas drogas. Não conhecia o réu. O local é conhecido como ponto de tráfico. Não havia outras pessoas no local.

No mesmo sentido, Paulo Franco Júnior – Guarda Municipal.

Interrogado, o réu FABIO disse que a droga encontrada em sua boca era para uso próprio. Negou os demais entorpecentes. Tinha comprado sete porções por vinte e cinco reais. É apenas usuário e não traficante de drogas.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas:

Visto em ponto de tráfico, sozinho e parado, o réu colocou algo na boca quando viu a viatura policial. Foi abordado. Porções de maconha foram encontradas em sua boca. E ainda portava dinheiro. Do outro lado da rua, após buscas, os agentes encontraram outras porções do outro lado da rua identicamente embaladas às porções que o réu trazia consigo. Os guardas deixaram claro que a conduta do réu deixou claro, somada às demais circunstâncias, que as drogas eram para o comércio ilícito: (i) o réu estava em local conhecido como ponto de vendas, e não ponto de uso de drogas; (ii) o réu estava sozinho e parado no local, ou seja, não podia ser o usuário-comprador simplesmente porque não havia, além dele mesmo, outra pessoa que pudesse ser a vendedora; (iii) e era ele quem vendia as drogas tanto que tinha dinheiro e sete porções de maconha em seu poder, as quais tentou esconder em sua boca; (iv) do outro lado da rua, mais porções, todas idênticas às que o réu trazia consigo; (v) prática comum, traficantes trazem consigo poucas porções e escondem o restante nas proximidades, buscando-as conforme as necessidades das vendas; (vi) não havia outras pessoas no local a quem pudessem ser atribuídas tais drogas, mesmo porque se sabe que traficantes não deixam entorpecentes abandonadas na rua ou em local sem vigilância, justamente porque possuem valor econômico no comércio ilícito de drogas.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: " A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito -

Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

Da pena:

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 29/34): FÁBIO LUIS DE PAIVA é tecnicamente primário - foi condenado como incurso no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 nos autos n.º 1501236-61.2020.8.26.0599

Possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, reconheceu que o chamado " tráfico privilegiado de drogas" não tem natureza hedionda.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento da Corte Superior e cancelo a Súmula 512.

Com isso, entendo possível, no presente caso, acompanhando o posicionamento das Cortes Superiores, a fixação de regime aberto e a substituição por restritiva de direitos.

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Fábio Luís de Paiva foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 83-85), no dia 09 de abril de 2021, por volta de 22h05, na rua José Alfredo de Castro Neves, n.º 13, Bairro Cecap, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Fábio trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 07 (sete) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., "maconha", com peso líquido de 8,6g (oito gramas e seis decigramas), bem como guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 18 (dezoito) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., "maconha", com peso líquido de 31g (trinta e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, Fábio estava realizando a mercancia ilícita em via pública. Para dificultar a ação repressiva, trazia poucas porções nas mãos para a venda e escondia outras em um arbusto próximo. Ocorre que, ao notar a aproximação de uma viatura policial, escondeu algumas porções de droga na boca e tentou sair furtivamente. Mas foi abordado pelos agentes que visualizaram seu comportamento evasivo. Na busca pessoal, os guardas encontraram em seu bolso a quantia de R\$25,00 (vinte e cinco reais) e sete porções de maconha em sua boca. Num arbusto do outro lado da via, localizaram outras 18 (dezoito) porções idênticas àqueles que o réu trazia consigo.

Interrogado em solo policial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 4).

Paulo Franco Júnior, guarda municipal, narrou que: "estava em patrulhamento de rotina pelo Bairro Cecap, nas imediações do terminal de ônibus. Ao adentrar na rua Alfredo José de Castro Neves, viu um indivíduo sozinho, parado na via. Ocorre que, ao avistar a viatura, tal indivíduo, ora indiciado, colocou algo suspeito na boca e tentou deixar o local, sendo abordado na sequência. Em revista pessoal, foi encontrado dinheiro em espécie no bolso do indigitado. Ademais, foi constatado que em sua boca havia sete porções de substância aparentando ser maconha. O implicado confessou informalmente que realizava o tráfico de drogas no momento da abordagem. Após realizar buscas nas imediações, encontrou mais dezoito porções de substância aparentando ser maconha escondidas num arbusto do outro lado da via, as quais apresentaram-se idênticas àqueles localizadas na posse do indigitado" (fls. 2). No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Joel Vasconcelos de Lima (fls. 3).

Às fls. 30, juntada certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido.

Às fls. 145-155, manutenção da negativa de ANPP.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, fotografia de fls. 14, laudo de constatação de fls. 17-19 e laudo de exame definitivo de fls. 126-128.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

Ouvida, inicialmente, Joel Vasconcelos de Lima. Alegou que estava fazendo patrulhamento e o réu se mostrou nervoso e colocou algo na boca. Abordado, encontraram com ele R\$25,00 e, na boca, 7 porções de maconha. Nas proximidades, foram encontradas mais drogas, do outro lado da calçada. O réu teria confessado

informalmente a traficância. O réu estava sozinho e parado quando o avistaram. O réu não tentou fugir, permaneceu no local com a droga na boca. Depois, perguntado novamente sobre o que disse o réu sobre a droga que foi encontrada, disse que não se recorda. Depois disse que o réu falou, quanto à droga que estava na boca, que era dele e estava traficando. As drogas encontradas do outro lado da rua eram idênticas às que ele estava na boca. O local do tráfico era próximo a uma escola, se não se engana. Não conhecia o réu. Perguntado, disse que não avistou o réu em ato de traficância, trocando algo com alguém ou mexendo na moita onde encontraram as demais drogas. Perguntado sobre a técnica utilizada para distinguir usuários de traficantes em locais conhecidos pelo comércio de entorpecentes, disse que pela conduta. Disse que a conduta do réu gerou desconfiança. Disse que ele estava ali parado e que usuários saem andando. Perguntado por quanto tempo ficaram observando para garantir que o réu estava ali parado, disse que não ficaram observando porque quem faz campana é a polícia civil.

b) Em seguida, ouvido o guarda municipal Paulo Franco Júnior, guarda municipal. Relatou que estavam fazendo patrulhamento quando avistaram um indivíduo que colocou algo na boca. Pararam para abordagem e, em revista pessoal, encontraram dinheiro e 7 porções de maconha na boca. Fizeram diligências no local e, do outro lado da rua, encontraram o restante da droga apreendida. Não se recorda bem, mas acha que o réu disse que a droga era dele e que estava vendendo. Que se recorda, Fabio estava parado na esquina. Quando viu a viatura, virou e colocou algo na boca. Estava sozinho. Não conhecia o réu. Toda a droga estava embalada da mesma forma. Às perguntas da defesa, respondeu o mesmo que o companheiro de farda.

c) Por fim, foi interrogado o réu Fábio Luís de Paiva. Relatou que é eletricitista de manutenção. É solteiro e mora com os pais. Mora no bairro CECAP. Contou que é usuário de drogas e tinha ido ao local de tráfico para adquirir drogas. Realmente se assustou com a aproximação da guarda, pois temia ser preso com as drogas. É eletricitista e tem trabalho. Comprou a droga. Pagou R\$25,00 por 7 porções de maconha e ficou com R\$25,00 de troco. Tinha R\$50,00. Os traficantes desceram a rua e a guarda chegou. O restante da droga foi encontrada a 30 metros de onde estava. Quando foi preso, estava perdido no vício, usava tudo, crack, cocaína, maconha, álcool. Não tem nada contra os guardas. Quando os guardas lhe questionaram, explicou que as drogas eram suas, para uso.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal. Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita. Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal.

Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelas guardas municipais, logo após a visualização do imputado, elas efetuaram a abordagem imediatamente por considerarem que ele ao visualizar a viatura o réu “colocou algo suspeito na boca”; o averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante

e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extraí-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157).

E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao réu.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Caso se entenda pela licitude da atuação da guarda, de rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

No caso concreto, é certo que o réu é usuário de drogas e conhecido na vara, uma vez que já foi processado outra vez e teve a sua conduta desclassificada para o uso de entorpecentes (processo n. 1501471-91.2021.8.26.0599). Nesse processo, a testemunha João Monteiro relatou que reside próximo ao réu e, por ser eletricista, já o contratou para fazer serviços. É de seu conhecimento que Fabio é usuário de drogas. Ele tem comércio e Fabio sempre estava nas imediações. Não tem conhecimento de que Fabio vendia entorpecentes. Sabe que Fabio não tem trabalho fixo, mas fazia bicos como eletricista, era demandado por diversas pessoas. Fazia pequenos serviços e recebia em dinheiro, não sabia que ele tinha máquinas de cartão ou outra forma de recebimento. Nunca ouviu boatos no bairro de que Fabio era traficante, mas sim de que era usuário. Já deu conselhos a ele a respeito. A rua em que foi preso é no bairro.

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada

apenas nas declarações dos guardas, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, caso se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, “No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho “Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos”, de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52,

mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

Outrossim, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder dos acusados se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, e mostra-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Da absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição em razão da inconstitucionalidade do referido tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual fere o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344).

Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do

entorpecente.

Desse modo, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas.

Diante da alegação ora invocada, de rigor seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, com consequente afastamento da imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas e absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Da aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há que se reconhecer a confissão, ainda que apenas a informal e mesmo que a pena não sofra alteração.

c) Da aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo. Processos em curso não são aptos a afastar o benefício e, conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto. Caso o privilégio seja reconhecido, requer seja fixado regime aberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Finalmente, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do

STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

FÁBIO LUIS DE PAIVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de abril de 2021, por volta de 22h05, na Rua José Alfredo de Castro Neves, n.º 13, Bairro Cecap, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 07 (sete) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., "maconha", com peso líquido de 8,6g (oito gramas e seis decigramas), bem como guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 18 (dezoito) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., "maconha", com peso líquido de 31g (trinta e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, FÁBIO - que ostenta envolvimento anterior com tráfico de drogas (em 26.09.20 foi preso em flagrante por tráfico de drogas na mesma região: foi denunciado nos autos n.º 1501236-61.2020.8.26.0599, em trâmite nessa E. Vara Criminal) - estava realizando a mercancia ilícita em via pública. Para dificultar a ação repressiva, trazia poucas porções nas mãos para a venda e escondia outras em um arbusto próximo.

Ocorre que, ao notar a aproximação de uma viatura policial, escondeu algumas porções de droga na boca e tentou sair furtivamente. Mas foi abordado pelos agentes que visualizaram seu comportamento evasivo.

Na busca pessoal, os guardas encontraram em seu bolso a quantia de R\$25,00 e sete porções de maconha em sua boca. Num arbusto do outro lado da via, localizaram outras 18 porções idênticas àqueles que o réu trazia consigo (foto fls. 14).

Na delegacia, FÁBIO ficou silente (fls. 04/05).

O exame pericial constatou a presença de Tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (laudo fls. 17/19).

Considerando as circunstâncias da prisão, notadamente a condição pessoal do agente - prisão em flagrante anterior por idêntica conduta (fls. 33, autos 1501236-61.2020.8.26.0599), a visualização do comportamento furtivo pelos agentes (fls. 02/03), a quantidade e forma de fracionamento das drogas (fls. 14), bem como a apreensão de dinheiro em espécie (R\$ 25,00), é certo que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 82), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 93/94).

Notificado (fls. 105), o réu apresentou defesa prévia, na qual alegou inocência e postulou o envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para nova análise sobre o acordo de não persecução penal (fls. 109/111).

O Ministério Público não ofereceu o acordo de não persecução penal (fls. 114/124) e o Procurador-Geral de Justiça insistiu nesse posicionamento (fls. 145/155)

A denúncia foi recebida, designando-se audiência virtual (fls. 129/131). O réu foi citado (fls. 169).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I) Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade da prisão, em razão de ter sido realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que apenas efetuavam patrulhamento de rotina pelo local e abordaram o réu em atitude suspeita, pois escondeu algo dentro da boca, quando os avistou.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto o réu foi abordado na posse dos entorpecentes apreendidos, dentro de sua boca, logo após os guardas municipais o avistarem em atitude suspeita, havendo, portanto, flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.954/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Da mesma forma, a Sexta Turma do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição com fulcro no inciso VI, do art. 386, do CPP - Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Provas ilícitas - Inocorrência - Precedente STF e TJSP - Autoria e materialidade delitiva

comprovadas - Condenação que se impõe - Causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas devida no patamar mínimo - Imposição de regime inicial fechado - Recurso provido, portanto. (TJSP; Apelação 0001473-09.2016.8.26.0536; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 30/10/2018).

PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. O fato de a prisão do acusado em flagrante ter sido efetuada por guardas municipais em serviço não implica em nulidade do processo. Não demonstração de prejuízo à defesa. Inexistência de abuso ou ilegalidade na diligência realizada. Disposição do artigo 301 do Código de Processo Penal que não é afastada pela norma do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Pelo contrário, a condição de agentes públicos corrobora a idoneidade dos atos dos guardas municipais. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Acusado preso em flagrante delito tendo em depósito, em conjunto com adolescente, de 19 porções de cocaína. Guardas confirmaram a apreensão dos entorpecentes e dinheiro. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal, ausentes circunstâncias exasperantes. Inexistência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Mantida a majorante relativa ao artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, ante a comprovação do envolvimento de adolescente na traficância. Afastada a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da mesma Lei nº 11.343/06, diante da frágil comprovação quanto à natureza das atividades desenvolvidas no estabelecimento indicado na denúncia e de sua proximidade em relação ao local da traficância. Pena redimensionada para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa mínimos. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. Demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se de rigor o perdimento do valor apreendido por ocasião da prisão flagrancial, por se tratar de produto do crime, ao que se soma a ausência de demonstração da sua origem lícita. REGIME. Manutenção do regime inicial fechado. Gravidade concreta do delito diante da natureza da droga apreendida, bem como o envolvimento de adolescente na prática. BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal, anotada a insuficiência da repressão delitiva caso concedida qualquer dessas benesses. Rejeição da preliminar e, no mérito, recurso defensivo provido parcialmente para redução da pena. (TJSP; Apelação 0012875-56.2016.8.26.0320; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de Registro: 11/10/2018 - grifei).

II - Do Mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 13, na fotografia de fls. 14, no laudo de constatação preliminar de fls. 17/19, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 126/128, segundo o qual foi detectada a presença de Tetrahydrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu calado (fls. 04).

Em Juízo, o réu afirmou que foi ao local para comprar 07 porções de maconha. Tinha R\$ 50,00 e adquiriu as 07 porções por R\$ 25,00, ficando com o troco. Quando tinha acabado de comprar, a viatura virou e ficou com medo, acabando colocando a droga na boca. Foi abordado. Os policiais encontraram a droga em outro lugar, a 30 metros de onde estava, do outro lado da rua, mas não tem relação com ela. É usuário e não tem necessidade de vender drogas. Faz uso de crack, cocaína, maconha e não conseguia ficar sem a droga. Assim que comprou a droga, os vendedores desceram a rua e ele estava subindo, quando foi abordado. Não tem necessidade de traficar drogas. Disse aos policiais que tinha ido ao lugar, comprar drogas para seu uso. Foi julgado há pouco tempo nesta Vara e trouxe testemunha, sendo absolvido.

A negativa de autoria não foi comprovada pelos demais elementos de prova existentes nos autos. Vejamos.

O guarda municipal Paulo Franco Júnior relatou que estavam em patrulhamento, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou indivíduo que, ao avistar a viatura, colocou algo na boca, chamando a atenção. Ele foi abordado e, na sua boca, havia 07 porções de maconha. Em varredura nas proximidades, do outro lado da rua, encontraram mais 18 porções da mesma droga, embalada de forma idêntica. O réu, se não se engana, acabou confessando que a droga era dele e a estaria vendendo. Quando avistaram o réu, ele estava parado na esquina e só se virou, colocando algo na boca. Ele estava sozinho e não havia outras pessoas na esquina. Não conhecia o réu. o local não é conhecido como de uso de drogas. A forma como o réu colocou a droga na boca chamou a atenção e o abordaram. Depois, ele confessou e o levaram à Delegacia. O usuário compra e rapidamente sai do local e o vendedor fica no local. Não fizeram

O também guarda municipal Joel Vasconcelos de Lima narrou que estavam em patrulhamento em local já conhecido por tráfico de drogas